

1502313-78.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... da Juventude, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (cf. fls. 49 e 58), também era conhecido nos meios policiais, por envolvimento com tráfico de drogas. Ainda, para além do depoimento dos policiais militares, consta também prova documental, tal como a degravação constante de fls. 122/126 dando conta de diálogo existente em aplicativo de comunicação, na qual um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502313-78.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502313-78.2021.8.26.0047 - 2021/002215

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ERIC LEANDRO DA SILVA DIONIZIO

Juiz de Direito: Dr. BRUNO CÉSAR GIOVANINI GARCIA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ERIC LEANDRO DA SILVA DIONIZIO, qualificado nos autos (fl. 19), denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 19 de agosto 2021, por volta das 19h10, na Rua da Fortuna, altura do nº 210, neste Município e Comarca, supostamente transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 4 (quatro) porções de maconha, com peso líquido total de 86,75 g (oitenta e seis gramas e setenta e cinco centigramas) [fls. 116/118].

O acusado foi notificado (fl. 133) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 140/141), a denúncia foi recebida (fls. 152/155).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas presentes e o réu interrogado. Em sede de alegações finais, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 176/184). A d. Defesa, após tecer considerações sobre as provas, pleiteou pela absolvição, ou subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ou, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-se regime aberto para início do cumprimento de pena (fls. 189/194).

É o relatório. Fundamento e decido.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelos laudos periciais (fls. 16/18, 106/108 e 122/126), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria também é certa e recai sobre o denunciado. A testemunha Paulo Victor, policial militar, relatou que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina pela ROCAM, de motocicletas, ocasião na qual se depararam com o acusado em via pública, saindo do Bairro Maria Isabel, andando de motocicleta. Era período noturno. A motocicleta dele estava com escapamento barulhento e farol traseiro queimado, razão pela qual fizeram a abordagem. Ele também conduzia em alta velocidade. Ele não obedeceu sinal de parada e começou a se evadir da equipe policial, momento no qual ele arremessou alguns objetos durante a fuga, situação que o depoente visualizou bem tal fato. O depoente em razão disso parou para recolher os objetos largados pelo acusado enquanto os demais policiais continuaram o acompanhamento. Após, foi atrás dos demais colegas e do acusado, localizou a equipe já realizando a busca pessoal no acusado. O depoente chegou, conversou com os demais policiais e questionou o Eric o motivo pelo qual ele teria arremessado os objetos, no início ele negou e depois, ao ver que o depoente teria conseguido pegar a droga, ele teria confirmado a posse da substância, aduzindo que era para consumo. O acusado já era conhecido do depoente de outra abordagem policial. Afirmo que em outras oportunidades o acusado já teria sido abordado pela equipe e até mesmo relatado que já teria realizado tráfico de drogas, mas que teria parado. Ele teria relatado nessa outra oportunidade que entregava de tudo, mas que ganhava dez reais por entrega, disso que veio a situação do "delivery". Quanto à motocicleta, no dia da prisão, ele falou que seria de um tio dele que pegou emprestado. Ele não soube falar o nome do tio. Verificaram que ela estava com peças alteradas no motor. A localidade da abordagem e onde foi arremessada a droga era conhecida pela venda de drogas. Com o acusado foi encontrado nove reais. Depoente não se recorda do celular do acusado ter sido apreendido. Não sabe dizer se a mãe do acusado tem loja ou da origem do dinheiro da outra oportunidade que apresentou. A testemunha Renato, policial militar, obtemperou que estavam em patrulhamento pela ROCAM, estavam em três policiais. Estavam pelo bairro Maria Isabel, localizaram uma motocicleta Titan cor verde, ela cruzou com a lanterna apagada. Assim que notou a presença da polícia, o condutor que já estava rápido, ao visualizar começou a se evadir pelo bairro. A equipe deu sinal sonoro e luminoso de parada, o qual não foi obedecido. Após alguns quarteirões o policial Negrini visualizou o indivíduo colocando a mão no bolso e arremessando algo em via pública, ele parou e deu sinal para os demais continuarem no acompanhamento. O policial Negrini recolheu os objetos, enquanto o restante da equipe acompanhou e abordou o condutor, na Rua Fortuna, uns quatro quarteirões. O depoente fez revista pessoal no acusado, encontrando nove reais, bem como um aparelho celular. Indagado, o acusado falou que não havia jogado ou dispensado nada. Após o policial Negrini mostrar os objetos, o acusado assumiu que era dele, mas falou que era para consumo, tendo sido preso e conduzido para a Delegacia. O acusado relatou que a motocicleta era de um tio dele, morador do Parque Universitário, mas não deu outros detalhes, não falou o nome e endereço. A moto foi recolhida no pátio administrativa, até porque o acusado não era habilitado. O indivíduo foi abordado porque estava em velocidade acima da permitida, farol apagado e também porque não obedeceu ordem de parada. O local ali é conhecido como de venda de drogas. Vários indivíduos já forma presos ali nas proximidades. Ele não foi pego em situação de mercancia, mas com o transporte. O aparelho celular dele foi apresentado no DP, a equipe não analisou o celular. A informante Gisele, arrolada pela defesa, disse que em relação aos fatos sabe que seu filho é usuário de maconha. Ele faz consumo de drogas há bastante tempo, desde os quatorze anos. A depoente tem loja em camelô, o Eric ajuda a depoente trabalhando no local, paga R\$ 1000,00 por mês para ele e R\$ 200,00 de vale, paga entre o dia 15 ao dia 20. Ele costuma comprar drogas. Ele é um excelente filho e bom funcionário. Se recorda de que em outra data houve uma abordagem policial com o Eric que foram até sua residência. Quando ele era menor de idade já foi pego com droga, ele cumpriu medida socioeducativa, não se recorda qual, mas não foi em Assis, foi em fundação casa. Ele não tem veículo nenhum. Essa motocicleta seria de um amigo dele.

Em interrogatório judicial o denunciado ERIC aduziu que ois fatos não são verdadeiros. Os entorpecentes eram para seu consumo pessoal. Confirma que estava com a droga. Estava em uma motocicleta. O depoente tinha acabado de comprar quatro porções de maconha, estava voltando para a casa, mas aí lembrou que precisava trocar o óleo. Estava indo para a oficina. Foi abordado pelos policiais. Confessou aos policiais que estava com quatro porções. A droga estava no bolso do depoente, não dispensou na rua. Foi abordado dentro da oficina. Tinham mais pessoas, o mecânico e o dono da oficina. Essa droga dá para passar um mês. Pagou duzentos reais na droga. A motocicleta era de um colega do depoente. Tinha acabado de pegar. O amigo chama João. Na oficina estava com Francisco e Vítor Hugo. A oficina funciona até as 21h. Tio Arthur é o traficante que o depoente pega droga (referente à conversa de fls. 124). A droga era para um colega do depoente, só indicou, não para entregar. O depoente recebe R\$ 1200,00 por mês ajudando a mãe no camelódromo. O depoente é usuário desde os treze anos de idade.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A despeito da negativa apontada pelo ora denunciado, verifico que sua versão restou isolada, sem encontrar lastro probatório sólido a fim de dar credibilidade ao afirmado. De outra via, a versão dos policiais não pode ser desconsiderada, razão pela qual restou comprovado, para além da dúvida razoável, que de fato o acusado praticou o delito a ele imputado na denúncia.

Os policiais, que testemunharam em Juízo, foram uníssomos ao afirmar que avistaram o acusado em via pública, sendo que o que motivou o acompanhamento do réu foi o fato de que a lanterna da frente da motocicleta que ele dirigia estava apagada. Durante o acompanhamento, ao avistar a viatura, o acusado passou a dirigir em velocidade superior, em uma possível tentativa de evasão, oportunidade em que arremessou objetos na rua, os quais foram encontrados pelos milicianos, tendo sido confirmado se tratar de porções de entorpecente. Em abordagem policial, o acusado afirmou a propriedade da droga, aduzindo que havia adquirido para uso pessoal.

De se esclarecer, ainda, que nada há nos autos a indicar que o testemunho dos policiais militares não mereça crédito. Não há provas de que eles queiram deliberadamente prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática de crime.

No mais, a quantidade de entorpecentes e sua forma de acondicionamento levam à conclusão inequívoca de que o entorpecente não se destinava à consumo próprio, ressaltando-se, inclusive o teor do laudo pericial relacionado ao aparelho celular do denunciado (fls. 122/126), prescindindo de maiores aprofundamentos, notadamente porque os depoentes indicaram, também, que o acusado já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, na modalidade 'delivery'.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Prozada, assim, a existência material do crime imputado, em todos os elementos do tipo pena, bem como a autoria do denunciado, não existindo quaisquer elementos que excluam a ilicitude da conduta ou ainda dirimam a culpabilidade do acusado, é de rigor a condenação, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em conjunto com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, que dispõe que preponderam neste primeiro momento a natureza e quantidade da substância, a personalidade e conduta social do agente. Nessa toada, no que tange às circunstâncias dispostas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, não há o que se valorar neste momento. No mais, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistentes em culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade

do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, em geral, são neutras no caso concreto, não havendo o que se valorar. Consigno que a existência de processos em andamento, bem como a condenação por atos infracionais anteriores não podem ser valorados para fins de maus-antecedentes, personalidade ou, ainda, reincidência. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes. Há a atenuante referente à menoridade relativa do agente. Todavia, deixo de diminuir a pena, vez que essa já foi fixada no patamar mínimo na fase antecedente, de acordo com o disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantenho a reprimenda anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. A fim de que a referida circunstância seja reconhecida, é necessária a observância de quatro pressupostos de ordem cumulativa, ou seja, o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

E, no caso concreto, em que pese a primariedade técnica do agente, entendo que as circunstâncias em que praticado o tráfico afastam a aplicação da diminuição de pena, pois há sérios indicativos de que o crime em tela não se tratou de evento isolado na vida do denunciado.

Pelo que se extrai dos autos, o acusado, atualmente com 20 anos de idade, além de possuir passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (cf. fls. 49 e 58), também era conhecido nos meios policiais, por envolvimento com tráfico de drogas. Ainda, para além do depoimento dos policiais militares, consta também prova documental, tal como a degravação constante de fls. 122/126 dando conta de diálogo existente em aplicativo de comunicação, na qual um terceiro nomeado "Tio Arthur" estaria consultando o denunciado quanto à possibilidade da realização de entrega de entorpecentes em ao menos três locais diversos, isso em data de 14/08/21.

Dito isto, verifica-se que a intenção legislativa, em verdade, foi de punir com menor rigor o traficante de "primeira viagem", ou seja, aquele que tenha realizado o ilícito de maneira isolada em sua vida. O caso concreto, todavia, evidenciou o contrário.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO REDUTOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O

reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Portanto, deixo de reconhecer a referida causa de diminuição, mantendo-se a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

O regime inicial será o semiaberto, a teor do art. 33, §2º, c, do Código Penal, tendo em vista que a gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada, bem como em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas constantes do art. 59 do Código Penal, observado o disposto no art. 33, §3º, do mesmo diploma, o que impossibilita a fixação de

regime fechado, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal em que o Ministério Público move contra ERIC LEANDRO DA SILVA DIONIZIO, qualificado nos autos, para condená-lo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo pecuniário.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista a fixação de regime inicial diverso do fechado, entendo que é o caso de se revogar a prisão preventiva anteriormente decretada. Isso, pois, a fixação de regime inicial diverso do fechado, em cotejo com o período em que se encontra segregado cautelarmente, afasta a razoabilidade para manutenção do cárcere processual (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017; HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016). Expeça-se alvará de soltura 'clausulado'.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro, aparelho celular e motocicleta apreendidos - em favor da União (fl. 11).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Em consequência, determino a instauração de incidente para fins de alienação judicial eletrônica do automóvel e aparelho celular mencionado, em caráter cautelar.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA